

次の【事例】に関する後記アからカまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から6までのうちどれか。

【事 例】

司法警察員Xは、被疑者甲に係る麻薬及び向精神薬取締法違反（大麻所持）被疑事件に関し、被疑者甲が一人で居住するアパートの居室を捜索すべき場所とし、大麻及び大麻吸引具を差し押さえるべき物とする捜索差押許可状に基づき、その居室を捜索した。その際、被疑者甲は、その居室にいた。司法警察員Xは、その捜索において、大麻及び大麻吸引具を発見することができなかったが、ポーチに入った覚せい剤様の白色結晶や、血液の混じったような液体が入った注射器を発見した。そのため、司法警察員Xは、① 前記白色結晶につき、覚せい剤の予試験を実施したところ、覚せい剤であるとの試験結果が得られた。そこで、司法警察員Xは、② 被疑者甲を覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕し、③ 前記白色結晶を押収するとともに、④ 前記ポーチ及び前記注射器を押収した。また、司法警察員Xは、⑤ 被疑者甲が任意に尿を提出したので、これを押収した。さらに、司法警察員Xは、採血を拒否した被疑者甲の血液型を明らかにするため、被疑者甲をH病院に連れて行き、⑥ H病院の医師Yをして、被疑者甲の採血をさせた。（改）

【記 述】

- ア. 下線部①について、被疑者甲が予試験の実施に同意をしていれば、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受けなくても、覚せい剤の予試験を実施できる。
- イ. 下線部②について、被疑者を逮捕するに当たり、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受ける必要がない。
- ウ. 下線部③について、白色結晶を押収するに当たり、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受ける必要がない。
- エ. 下線部④について、ポーチ及び注射器を押収するに当たり、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。
- オ. 下線部⑤について、被疑者甲が任意に尿を提出しなかった場合でも、司法警察員Xは、捜索差押許可状の発付を受けて、医師をして被疑者甲から強制的に採尿をさせることができる。
- カ. 下線部⑥について、医師Yをして被疑者甲の採血をさせるには、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受けなくても、医師Yに鑑定嘱託をして、被疑者甲の採血をさせることができる。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ カ 5. エ オ 6. エ カ

* 令和5年法律第84号により大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」と題名を改正され、従来の大麻の所持等に関する取締規定は、「麻薬及び向精神薬取締法」第2条1項1号において「麻薬」の定義に大麻を含めることで対応することとなったため、出題時の問題文における「大麻取締法違反」は、「麻薬及び向精神薬取締法違反」となった。

ア 正しい

本記述では、被疑者の同意を得て覚せい剤の予試験を実施するには、裁判官による令状の発付を必要とするかが問題となる。

まず、捜査官の五官の作用により、場所・物・人の身体について、その性質・状態を実験・認識することを目的とする処分を、検証という。本記述のような覚せい剤の予試験は、捜査機関が五官の作用により、覚せい剤様の白色結晶について、その性質を実験・認識することを目的とする処分であるから、検証にあたる。

次に、捜査機関の行う検証には、強制処分としての検証と、任意処分としての実況見分とが存在する。本記述における予試験については、予め被疑者甲の同意が得られているため、強制処分としての検証ではなく、任意処分としての実況見分にあたる。そして、実況見分は任意捜査であるから、裁判官による令状の発付は必要ない。

よって、本記述では、甲が同意をしていれば、司法警察員Xは、裁判官による令状の発付を受けなくても、覚せい剤の予試験を実施できる。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい

212条1項、213条。本記述では、覚せい剤を所持していた被疑者を逮捕するためには、裁判官による令状の発付を必要とするかが問題となる。現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者は、現行犯人とされる(212条1項)。本件で、甲は覚せい剤であるとの試験結果の得られた白色結晶を所持しており、現に覚せい剤取締法違反の罪を行っているといえるので、現行犯人にあたる。そして、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(213条)。その趣旨は、現行犯の場合には、犯罪と被逮捕者との結び付きが明白で誤認逮捕のおそれがなく、かつ、その機会を逃すと今後いつ被疑者の身柄を保全できるか分からないという意味で急速な逮捕の必要性が一般的にあると認められるという点にある。よって、本記述では、司法警察員Xが、覚せい剤取締法違反の罪の現行犯人である甲を逮捕するにあたり、裁判官による令状の発付を受ける必要はない。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

220条1項2号。本記述では、覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕された者が所持していた白色結晶を押収するためには、裁判官による令状の発付を必要とするかが問題となる。

司法警察職員等は、逮捕をする場合において必要があるときは、逮捕の現場で差押え、搜索又は検証をすることができる(220条1項2号)。「逮捕の現場」の意義について、判例は、「場所的同一性を意味するとどまるものと解する」としている(最大判昭36.6.7、百選A6事件)。本件では白色結晶は甲が逮捕された現場に存在していたので、Xが白色結晶押収したのは「逮捕の現場」とであるといえる。

次に、逮捕の現場での搜索・差押えの目的物の範囲は、明文上限定されていないが、「必要があるとき」(220条1項柱書)という文言からは、逮捕を口実として一般的探索的な搜索・差押えが行われないよう、逮捕の理由となっている被疑事実に関する証拠物・没収すべき物に限られることになる。本事例で、被疑者甲は覚せい剤取締法違反の被疑事実で現行犯逮捕されており、また甲が所持していた白色結晶については、覚せい剤であるとの試験結果が得られている。それゆえ、白色結晶は甲に対する覚せい剤取締法違反の被疑事実に関する証拠といえる。

よって、司法警察員Xは220条1項2号により、白色結晶の差押えをするにあたり、裁判官による令状の発付を受ける必要はない。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

220条1項2号。本記述では、覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕された者が占有していた物を押収するためには、裁判官による令状の発付を必要とするかが問題となる。

司法警察職員等は、逮捕をする場合において必要があるときは、逮捕の現場で差押え、搜索又は検証をすることができる(220条1項2号)。「逮捕の現場」の意義について、判例は、「場所的同一性を意味するにとどまるものと解する」としている(最大判昭36.6.7、百選A6事件)。本事例では、白色結晶の入っていたポーチや注射器は甲が逮捕された現場に存在していたので、Xがこれらの物品を押収したのが「逮捕の現場」であるといえることができる。

次に、逮捕に伴う搜索・差押えの目的物の範囲については、明文上限定されていないが、「必要があるとき」(220条1項柱書)という文言からは、逮捕を口実として一般的探索的な搜索・差押えが行われないよう、逮捕の理由となっている被疑事実に関する証拠物・没収すべき物に限られることになる。本事例で、被疑者甲は覚せい剤取締法違反の被疑事実で現行犯逮捕されており、また甲が室内に占有していたポーチには白色結晶が入っていたほか、注射器には血液の混じったような液体が入っていたものである。それゆえ、これらの物件は、甲に対する覚せい剤取締法違反の被疑事実に関する証拠といえる。

よって、司法警察員Xは220条1項2号により、ポーチ及び注射器の差押えをするにあたり裁判官による令状の発付を受ける必要はない。したがって、本記述は、裁判官による令状の発付を受ける必要がないとすべきところ、裁判官による令状の発付を受ける必要があるとしている点で、誤っている。

オ 正しい

最決昭55.10.23(百選28事件)。本記述では、搜索差押許可状により、医師をして被疑者から強制的に採尿をさせることができるかが問題となる。

まず強制採尿そのものの可否につき、判例は、「被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、犯罪の捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経てこれを行うことも許されてしかるべきである」としている。本事例の覚せい剤取締法違反の被疑事実は重大であること、甲はその現行犯であるから覚せい剤使用罪の嫌疑も十分に存在すること、甲は尿の任意提出を拒んでいるため強制採尿に代わる適当な代替手段がないこと等に照らせば、本件でも強制採尿を実施することが許されることになる。

次に、強制採尿を実施するために必要となる適切な法律上の手続につき、判例は、「搜索差押令状を必要とする」としている。その理由として、判例は、「体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は搜索・差押の性質を有するものとみるべきである」ということを挙げている。

よって、司法警察員Xは上記の搜索差押令状の発付を受けて、医師をして被疑者甲から強制的に採尿をさせることができる。したがって、本記述は正しい。なお、上記判例は、強制採尿が「人権の侵害にわたるおそれがある点では、一般の搜索・差押と異なり、検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、身体検査令状に関する刑法218条5項(現218条6項)が右搜索差押令状に準用されるべきであって、令状の記載要件として強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わなければならない旨の条件の記載が不可欠である」としている。

カ 誤っている

本記述では、捜査機関が医師に鑑定嘱託をして被疑者の採血をさせるためには、裁判官による令状の発付を要するかが問題となる。身体への損傷を伴う内部検査は、鑑定に属する。採血は対象者の身体を損傷するものであるため、その性質は鑑定である。それゆえ、被疑者甲が採血を拒否している本事例において、医師に嘱託(223条1項)して鑑定としての採血を行わせることは、強制処分にあたることになる。よって、本事例で医師Yをして被疑者甲の採血をさせるには、225条1項により、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。

したがって、本記述は、裁判官による令状の発付を受けなければ、被疑者甲の採血をさせることはできないとすべきところ、令状の発付を受けなくてもこれをさせることができるとしている点で、誤っている。

なお、強制採血に令状が必要だとして、どのような方式の令状が必要かが問題となる。鑑定処分許可状について 225 条 4 項の準用する 168 条 6 項は、直接強制を可能とする 139 条を準用しておらず、また 225 条 4 項は直接強制を可能とする 172 条を準用していない。そのため、鑑定受託者である医師は、鑑定処分許可状だけでは、対象者が採血に応じない場合に採血の直接強制を行うことができない。そこで、実務では鑑定処分許可状及び、直接強制が可能な身体検査令状（218 条 1 項後段、222 条 1 項後段・139 条）を併用する取扱いがなされている。

以上により、誤っている記述はエとカであり、したがって、正解は肢 6 となる。